А.Е. Якубов, *кандидат юридических наук, федеральный судья в отставке, заслуженный юрист РФ, доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета МГУ**

ДЕЙСТВИЕ УГОЛОВНОГО ЗАКОНА ВО ВРЕМЕНИ: ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЗАКОНА

Статьи 9-10 УК РФ регулируют вопросы действия уголовного закона во времени и обратную силу уголовного закона. Со времени введения УК РФ в действие с 1 января 1997 г. они не подвергались изменению. Анализируя уголовное законодательство Республики Беларусь, Республики Украина, Литовской Республики, Республики Армения, усовершенствовавших соответствующие положения в своих уголовных кодексах, автор предлагает внести аналогичные изменения в УК РФ, а также вносит предложение по вопросу создания «процессуального механизма» применения обратной силы уголовного закона.

Ключевые слова: действие закона во времени, обратная сила уголовного закона, время совершения закона, условно-досрочное освобождение, категоризация преступлений, «промежуточный» закон, «процессуальный механизм».

Articles 9–10 of the Criminal Code govern the operation of criminal law in time and retroactivity of criminal law. Since coming into force of the Criminal Code on January 1, 1997 these articles stayed unaltered. Analyzing the criminal legislation of the Republics of Belarus, Ukraine, Lithuania and Armenia who improved relevant provisions in their criminal codes, the author proposes to make similar changes to the Criminal Code, as well as makes a proposal for the establishment of "procedural mechanism" of retroactive application of criminal law.

Keywords: retroactivity of criminal law, operation of law in time, time of the law, parol, categorization of offenses, “intermediate” law, “procedural mechanism”.

Уголовный кодекс РФ по вопросам действия уголовного закона во времени в сравнении с Уголовным кодексом РСФСР предусмотрел три новеллы: 1) УК РФ уточнил определение времени совершения преступления (ст. 9 УК РФ, ч. 1 ст. 6 УК РСФСР), 2) УК РФ распространил обратную силу не только на законы, устраняющие преступность деяния или смягчающие наказание, как было предусмотрено ч. 2 ст. 6 УК РСФСР, но и на законы, иным образом улучшающие положение лица; и, соответственно, исключил обратную силу как уголовного закона, устанавливающего преступность деяния или усиливающего наказание, так и закона, иным образом ухудшающего положение лица (ч. 1 ст. 10 УК РФ); 3) согласно ч. 2 ст. 10 УК РФ, «если новый уголов-

* criminal@law.msu.ru

ный закон смягчает наказание за деяние, которое отбывается лицом, то это наказание подлежит сокращению в пределах, предусмотренных новым уголовным законом», тогда как согласно внесенной Законом РСФСР от 5 декабря 1991 г. ч. 3 в ст. 56 УК РСФСР, «подлежит смягчению назначенное осужденному наказание, превышающее верхний предел санкции вновь изданного уголовного закона, которым смягчается наказание за деяние, совершенное осужденным. Назначенное судом наказание при этом смягчается до меры, установленной верхним пределом санкции вновь изданного уголовного закона»: согласно ч. 2 ст. 56, «осужденный подлежит освобождению от наказания за совершение деяния, преступность и наказуемость которого были после вступления в законную силу приговора суда, назначившего это наказание, устранены уголовным законом»[1].

Перед авторским коллективом, работавшим над созданием проекта нового УК, была поставлена задача — как можно дальше отойти от УК РСФСР, вследствие чего в УК РФ было допущено немало упущений, недостатков (исключили прерывание сроков давности привлечения к уголовной ответственности при совершении лицом нового преступления[2], понятие «рецидивист» заменили понятием «рецидив преступлений», без необходимости изменили назначение наказания по совокупности преступлений и по совокупности приговоров и др.). Об этом также свидетельствует то, что с момента введения в действие УК 1996 г. (1 января 1997 г.) Государственной Думой на 19 октября 2013 г. принято 132 федеральных закона, внесших изменения и дополнения в УК РФ. Как отмечает А. Коробеев, «к настоящему моменту в Уголовный кодекс России в том или ином виде внесено уже около тысячи изменений. Это означает, что в некоторые статьи УК изменения вносились неоднократно, а в отдельные — по пять-шесть раз»[3]. Однако ни одно из этих изменений не коснулось ни ст. 9 (Действие уголовного закона во времени), ни ст. 10 (Обратная сила уголовного закона). Очевидно, возникла необходимость в обобщенном виде напомнить высказанные в печати предложения о совершенствовании уголовного законодательства о действии уголовного закона во времени и проанализировать другие проблемы, возникшие в судебной практике при применении ст. 9, 10 УК РФ.

1. При решении вопросов, касающихся действия уголовного закона во времени, принципиальное значение имеет вопрос, что считать временем совершения преступления. Согласно ч. 1 ст. 6 УК РСФСР, преступность и наказуемость деяния определялись законом, действо-

---

[1] Трудно объяснить, почему указанные изменения внесены Законом РСФСР от 5 декабря 1991 г. в ст. 56 УК РСФСР (Освобождение от отбывания наказания), а не в ст. 6 (Действие уголовного закона во времени).

[2] См.: *Якубов А.Е.* Сроки давности в уголовном праве // Законность. 2010. № 8.

[3] *Коробеев А.* Лоскутное одеяло Уголовного кодекса // Независимая газета. 2013. 13 февр.

вавшим во время совершения этого деяния. Но по некоторым преступлениям последствия наступают через некоторое время после совершении действий или допущенного бездействия, вследствие чего возникает вопрос: какой закон следует применять, если новый закон, внесший изменения в УК, вступил в силу между действием (бездействием) и наступившим последствием? Некоторые авторы считали, что временем совершения преступления в подобных случаях следует считать время наступления последствий. Такое мнение высказывал, в частности, Н.С. Таганцев. Данная позиция вытекала из общей позиции ученого о применении во всех случаях более позднего закона, даже если это более строгий закон[4].

Согласно ч. 2 ст. 9 УК РФ, временем совершения преступления признается время совершения общественно опасного действия (бездействия) независимо от времени наступления последствий. Решая таким образом вопрос, законодатель исходил из принципа субъективного вменения, согласно которому сознанием лица должны охватываться общественная опасность и противоправность совершаемых им действий (бездействия). Однако относительно времени совершения преступления не все проблемы были решены. Уголовные кодексы зарубежных государств (бывших союзных республик) некоторые из этих проблем уже решили.

Так, виновный может сознавать, что в результате совершенных им действий последствия наступят позднее, когда будет действовать более строгий закон. В таких случаях в соответствии с принципом субъективного вменения временем совершения преступления следует считать время наступления последствий.

Именно такой случай предусмотрен УК Литовской Республики. По общему правилу (ч. 1 ст. 3) временем совершения преступления признается, как и по ч. 2 ст. 9 УК РФ, время совершения действия (бездействия). Вместе с тем, если виновный желал наступления последствий в другое время, когда действовал более строгий закон, то «временем совершения преступления следует считать время наступления последствий»[5].

---

[4] См.: *Таганцев Н.С.* Русское уголовное право. Часть Общая. Спб., 1902. Т. 1. С. 277. Аналогичное мнение о времени совершения преступления высказали А.Н. Игнатов (см.: *Игнатов А.Н.* Введение в изучение уголовного права. Уголовный закон // Уголовное право. Общая часть. Курс лекций. Лекция 1. М., 1996. С. 25, 26), С.Ф. Милюков (см.: *Милюков С.Ф.* Российское уголовное законодательство. Опыт критического анализа. СПб., 2000. С. 48). Анализ указанных позиций см.: *Якубов А.Е.* Обратная сила уголовного закона. СПб., 2003. С. 31–43.

[5] Уголовный кодекс Литовской Республики. Вильнюс, 1997. С. 5. Вместе с тем в УК Литовской Республики указано, что обратную силу имеют нормы, устанавливающие ответственность за геноцид, запрещаемое международным правом обращение с людьми, убийство людей, охраняемых международным гуманитарным правом, депортацию гражданских лиц оккупированного государства, причинение вреда здоровью, пытки или иное бесчеловечное обращение с лицами, охраняемыми международным гуманитарным

Очевидно, и в нашем Уголовном кодексе следует предусмотреть подобное положение.

В УК РФ не решен вопрос о том, что следует считать временем совершения преступления соучастником. Одни авторы считают временем совершения преступления соучастниками время совершения действий исполнителем[6]. Представляется более убедительной другая точка зрения, согласно которой при совершении преступления соучастником время должно определяться моментом последнего из инкриминируемых каждому из них действий[7]. Доводом в пользу этой позиции является то, что в противном случае невозможна ответственность соучастника за приготовление к преступлению при добровольном отказе исполнителя от доведения преступления до конца. В случае если соучастник предвидел, что исполнитель совершит свои деяния в период действия более строгого закона, соучастник несет ответственность по этому закону. Более того, следует распространить правило о признании временем совершения преступления и на действия соучастника при совершении преступления с отдаленным результатом, т.е. в этих случаях временем совершения преступления для соучастников, как и для исполнителя, должен быть момент наступления последствий. Следовало бы внести в ч. 1 ст. 9 УК РФ соответствующее положение об определении времени совершения преступления соучастником.

2. Статьи 53, 53', 55 УК РСФСР, регулировавшие вопросы условно-досрочного освобождения, постоянно изменялись в сторону ограничения условно-досрочного освобождения. Суды рассматривали эти вопросы в соответствии с Постановлением Пленума Верховного Суда СССР от 18 декабря 1963 г., которым разъяснялось, что вопрос о возможности применения или неприменения условно-досрочного освобождения от наказания и замены неотбытой части наказания более мягким должен решаться в соответствии с действующим на данный момент законом, а не на основе законодательства, действовавшего во время совершения преступления[8]. Такое разъяснение ухудшало положение осужденных.

УК РФ распространил обратную силу закона не только на преступность и наказуемость, но и на закон, иным образом улучшающий положение лица, совершившего преступление и соответственно исключил обратную силу в отношении законов, иным образом ухудшающих положение лица (ч. 1 ст. 10 УК). К таким законам относятся в

правом, принудительное использование гражданских лиц или военнопленных в вооруженных силах противника, запрещенную военную атаку (ч. 3 ст. 3).

[6] См.: *Дурманов Н.Д.* Советский уголовный закон. М., 1967. С. 263; *Брайнин Я.М.* Уголовный закон и его применение. М., 1967. С. 137.

[7] См.: *Мокринский С.П.* Новый закон и старые гарантии (о действии уголовного закона в пределах времени). Спб., 1909. С. 21.

[8] Сборник Постановлений Пленума Верховного Суда СССР. 1924–1970. М., 1970. С. 373.

первую очередь законы об условно-досрочном освобождении и замене наказания более мягким, а также законы о давности привлечения к уголовной ответственности и исполнении обвинительного приговора, иные законы об освобождении от уголовной ответственности или наказания, закон о погашении или снятии судимости и др.

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда РФ от 24 апреля 2012 г. отменила решения судов первой, а также кассационной и надзорной инстанций Пермской области, отказавших Х. в условно-досрочном освобождении по тем основаниям, что осужденный не отбыл ¾ назначенных Х. наказания, предусмотренных новой редакцией п. «б» ч. 3 ст. 79 УК РФ (в ред. от 3 ноября 2009 г.)

Судебная коллегия указала следующее: Х. осужден по приговору суда от 25 декабря 2006 г. за тяжкое преступление, предусмотренное пп. «в», «д» ч. 2 ст. 131 УК РФ. На момент совершения преступления и на момент вынесения приговора действовала норма закона, предусмотренная п. «б» ч. 3 ст. 79 УК РФ (в ред. от 9 марта 2001 г.), устанавливающая возможность применения условно-досрочного освобождения от наказания осужденного после фактического отбытия им не менее половины срока наказания, назначенного за тяжкое преступление. Отказывая Х. в условно-досрочном освобождении, суды первой, кассационной и надзорной инстанций не учли, что в силу ст. 10 УК РФ закон, иным образом ухудшающий положение лица, обратной силы не имеет.

Судебная коллегия решения судов отменила и дело направила на новое рассмотрение в тот же суд иным составом суда[9].

3. Не представляет сложности определить, какому закону следует отдать предпочтение, если новый закон смягчает наказуемость деяния в одном из пределов санкции, оставляя без изменений другой предел санкции, либо снижает наказуемость деяния в обоих пределах.

Сложность представляют случаи, когда новый закон усиливает наказание в одном из пределов и смягчает наказание в другом. Дискуссия о том, какой закон в таких случаях следует признать более мягким, продолжается более ста лет. Законодательство некоторых государств предоставляло право выбора самому обвиняемому. Не прошла эта проблема мимо внимания и российских криминалистов. Так, Н.А. Неклюдов в 1875 г. писал, что «ежели старый закон будет частью строже, частью мягче нового, следует применять всегда ту часть закона, которая снисходительна к подсудимому»[10]. М.Д. Шаргородский

[9] Бюл. Верховного суда РФ. 2012. № 11. С. 36–37.

[10] *Неклюдов Н.А.* Общая часть уголовного права: конспект. Спб., 1875. С. 174. Аналогичной позиции придерживались также Н.С. Таганцев (см.: *Таганцев Н.С.* Курс русского уголовного права, читаемый в императорском Спб. университете: Часть Общая. Спб., 1879–1880. С. 94), С.П. Мокринский (см.: *Мокринский С.П.* Новый закон и старые гарантии (о действии уголовного закона в пределах времени). Спб., 1909. С. 19). Различные мнения по этой проблеме высказывали также советские ученые: Сахаров А.Б. (Ответственность за деяния, совершенные до вступления в силу Уголовного кодекса РСФСР // Соц.

высказал мнение, перекликающееся со взглядами дореволюционных российских криминалистов. «Более мягким следует признать такой закон, — писал М.Д. Шаргородский, — который, будучи применен в данном конкретном случае, приведет к наиболее благоприятным для подсудимого результатам»[11].

Однако с таким подходом вряд ли можно согласиться. В каких пределах следует определить наказание подсудимому — в пределах более низкого минимума одного закона или в пределах более низкого максимума другого закона и, следовательно, какой закон является более благоприятным для подсудимого — решает суд, тогда как квалифицировать преступление необходимо уже в стадии предварительного расследования. При этом руководствоваться необходимо не субъективными оценками (какой закон более благоприятен для обвиняемого), а объективными критериями.

С принятием нового Уголовного кодекса появились и новые принципиальные соображения в пользу решения этой проблемы. Ст. 15 УК РФ предусматривает категоризацию преступлений на преступления небольшой тяжести, средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие. В основание этой категоризации положено максимальное наказание, предусмотренное санкцией соответствующей статьи. Отнесение преступления к той или иной категории влечет очень серьезные последствия для осужденного, и поэтому в интересах подсудимого, чтобы его действия были квалифицированы по статье, санкция которой предусматривает более низкий верхний предел наказания.

Практика Верховного суда РФ дает основания для выводов о том, чем следует руководствоваться, если при квалификации преступления по верхнему пределу санкции нового закона возникла необходимость определения наказания в минимальных пределах, предусматривающих более строгое наказание в сравнении с прежним законом.

Принципиальное значение имеют решения Верховного суда РФ по делу Яремчук, делу Заморина и делу Могушкова, в отношении которых Военная коллегия Верховного суда РФ (в надзорном порядке), указывая, что санкция прежнего закона предусматривала в минимальных пределах более мягкое наказание, снизила наказание Яремчуку с 69 МРОТ до двух МРОТ (ч. 1 ст. 130 УК РСФСР, ч. 1 ст. 129 УК РФ), Заморину — с 2 504 700 руб. до одного МРОТ — 60 500 руб. (ч. 2 ст. 112 УК РСФСР, ст. 116 УК РФ), Могушкову с 520 000 руб. до одного МРОТ — 83 490 руб.[12].

Таким образом, следует сделать вывод: в случае принятия закона, смягчающего наказание, квалифицировать деяние следует по зако-

---

законность. 1961. № 6. С. 28), М.И. Блум и А.А. Тилле (см.: *Блум М.И., Тилле А.А.* Обратная сила закона. Действие советского уголовного закона во времени. М., 1969. С. 118–119) и др.

[11] *Шаргородский М.Д.* Уголовный закон. М., 1948. С. 226.

[12] Бюл. Верховного суда РФ. 2000. № 6. С. 17.

ну, предусматривающему более низкое наказание в верхних пределах санкции, а определять наказание в случае необходимости назначения наказания в минимальных пределах, руководствуясь санкциями в нижних пределах обоих законов.

Именно по такому пути (возможно, с учетом практики Верховного суда РФ) пошел украинский законодатель, который в ч. 3 ст. 5 УК, вступившего в силу с 1 сентября 2001 г., указал: «Закон об уголовной ответственности, частично смягчающий ответственность, а частично ее усиливающий, имеет обратное действие во времени лишь в той части, которая смягчает ответственность»[13].

По такому же пути пошел законодатель Республики Армения, предусмотрев в ч. 3 ст. 13 УК: «Закон, частично смягчающий ответственность и одновременно частично усиливающий ответственность, имеет обратную силу только в части, смягчающей ответственность».

Подобное положение следовало бы включить и в УК РФ.

4. Одним из сложных вопросов в проблеме обратной силы уголовного закона является вопрос действия «промежуточного» закона, который возникает, когда между временем совершения лицом преступления и временем привлечения этого лица к уголовной ответственности принимается два или более закона.

В уголовном законодательстве некоторых государств содержатся нормы, предусматривающие действие «промежуточного» закона. Так, согласно ч. 3 § 2 УК ФРГ, «если закон, который действовал в момент окончания деяния, изменяется перед принятием решения, то должен применяться самый мягкий закон»[14]. Аналогичное положение содержится в УК Республики Болгария, согласно ч. 2 ст. 2 которого, «если до вступления приговора в законную силу будут изданы законы, предусматривающие различные по своей тяжести наказания, то применяется тот закон, который является наиболее благоприятным для виновного»[15].

В Советском Союзе в отсутствие прямого указания в Уголовном кодексе практика применения «промежуточного» закона была противоречивой. Так, Пленум Верховного Суда СССР отменил постановление Пленума Верховного Суда БССР от 14 мая 1964 г., применившего «промежуточный» закон[16].

Автором в журнале «Российская юстиция» за 1998 г. № 8 была опубликована статья «Действие “промежуточного” закона», в которой анализировались позиции различных авторов по вопросу применения «промежуточного» закона, а также подвергалось критике указанное постановление Пленума Верховного Суда СССР.

---

[13] Уголовный кодекс Украины // Голос Украины. 2001. 19 июня. С. 5.

[14] Уголовный Кодекс ФРГ. М., 1996. С. 10.

[15] Уголовный Кодекс Республики Болгария. СПб., 2001. С. 28–29.

[16] Бюл. Верховного Суда СССР. 1965. № 2. С. 29–30.

Через некоторое время автору позвонила из Минска член Конституционного Суда Республики Беларусь профессор Э.А. Саркисова, участвовавшая в разработке проекта УК Республики Беларусь. В результате обсуждения проблемы «промежуточного» закона в принятом 2 июня 1999 г. Уголовном кодексе Республики Беларусь появилась ч. 4 ст. 9 следующего содержания: «Если действовавший во время совершения преступления уголовный закон был отменен или изменен уголовным законом, устраняющим преступность деяния, смягчающим наказание или иным образом улучшающим положение лица, совершившего преступление, но ко времени расследования уголовного дела или рассмотрения дела в суде вступил в силу иной более строгий уголовный закон, применению подлежит наиболее мягкий промежуточный закон»[17].

Примеру Республики Беларусь последовала Украина, включившая 15 апреля 2008 г. в ст. 5 ч. 4, согласно которой, «если после совершения лицом деяния, предусмотренного настоящим Кодексом, закон об уголовной ответственности изменялся несколько раз, обратное действие во времени имеет тот закон, который устраняет преступность деяния, смягчает уголовную ответственность либо иным образом улучшает положение лица»[18].

Заключая проводившийся в начале 1997 г. с судьями Верховного суда РФ семинар по вопросам обратной силы вступившего в законную силу Уголовного кодекса РФ, автор призвал судей: если у них в производстве окажется дело, по которому возникает вопрос о применении или неприменении «промежуточного» закона, высказаться в пользу применения такого закона.

Принципиальное значение имеют определения судебной коллегии Верховного суда РФ от 8 декабря 2000 г. и от 14 июня 2002 г. по делу Былининой и др. Приговором Тюменского областного суда от 6 мая 2000 г. Былинина, Бобылев, Бакустин и Фертиков, совершившие похищение человека 31 августа 1996 г., были осуждены: Былинина по ч. 2 ст. 125-1, а Бобылев, Бакустин и Фертиков по ч. 3 ст. 125-1 УК РСФСР. Определением судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда РФ от 8 декабря 2000 г. действия Былининой, Бобылева, Бакустина и Фертикова были переквалифицированы с ч. 3 ст. 125-1 УК РСФСР на ч. 2 ст. 126 УК РФ в редакции ФЗ РФ от 24 мая 1996 г. После отмены постановлением Президиума Верховного суда РФ указанного определения, вследствие того что в определении не был указан пункт ч. 2 ст. 126 УК РФ, при повторном кассационном рассмотрении 14 июня 2002 г. действия осужденных были переквалифицированы на п. «а» ч. 2 ст. 126 УК РФ в редакции ФЗ РФ от 24 мая 1996 г. Таким образом, два состава судебной коллегии по уголовным делам Верховного

[17] Комментарий к Уголовному кодексу Республики Беларусь. Минск, 2003. С. 31.
[18] ВВР Украины.2008. № 24. Ст. 23.

суда РФ высказались за применение «промежуточного» закона, предусматривающего более мягкое наказание в сравнении с законами, действовавшими в момент совершения преступления и в момент вынесения приговора (санкция ч. 2 ст. 125-1 УК РСФСР — лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества или без таковой, *ч. 2 ст. 126 УК РФ в редакции ФЗ РФ от 24 мая 1996 г. — лишение свободы на срок от 5 до 10 лет,* ч. 2 ст. 126 УК РФ в редакции ФЗ РФ от 9 февраля 1999 г. — лишение свободы на срок от 6 до 15 лет)[19].

Однако законодательного закрепления применение «промежуточного» закона пока не получило.

5. Центральной и наиболее острой проблемой действия уголовного закона во времени является проблема применения обратной силы уголовного закона. С наибольшей остротой проявляется эта проблема при применении обратной силы к лицам, отбывающим наказание. Согласно ч. 2 ст. 10 УК, «если новый закон смягчает наказание за деяние, которое отбывается лицом, то это наказание подлежит сокращению в пределах, предусмотренных новым уголовным законом». Однако никаких критериев, которыми следует руководствоваться при сокращении наказания в этих случаях, УК РФ не предусмотрел. Вследствие этого законодатель был вынужден Федеральным законом от 27 декабря 1996 г. внести изменения и дополнения в Федеральный закон «О введении в действие Уголовного кодекса Российской Федерации», которым (ФЗ от 27 декабря 1996 г.) было предусмотрено: «Меры наказания лицам, осужденным по ранее действующему уголовному закону и не отбывшим наказания, привести в соответствие с Уголовным кодексом Российской Федерации в тех случаях, когда назначенное им судом наказание является более строгим, чем установлено верхним пределом санкции соответствующей статьи Уголовного кодекса Российской Федерации».

Изменения ФЗ «О введении в действие Уголовного кодекса Российской Федерации», внесенные ФЗ от 27 декабря 1997 г., были рассчитаны только на приведение в соответствие квалификаций преступлений, наказаний и пр. с новым УК, однако судебная практика распространила положения ФЗ от 27 декабря и на последующие случаи применения обратной силы нового уголовного закона, смягчающего наказуемость деяния, в отношении осужденных, снижая наказание только до максимальных пределов, предусмотренных новым законом.

В печати нашлись сторонники подобного решения проблемы. Так, Г.И. Цепляева считает, что суд применяет аналогию закона, сокращая наказание с учетом обстоятельств, указанных в гл. 10 УК РФ об общих началах назначения наказания при приведении наказания в соответствие с новым законом (de facto за одно преступление наказа-

[19] Отдел обобщений судебной практики Верховного суда РФ. Дела № 89-000-76, № 89-001-88.

ние назначается дважды: один раз — по приговору суда, второй раз — постановлением)[20]. В этом Г.И. Цепляева усматривает нарушение принципа законности, который предполагает единообразное применение нормы и исключает допустимость противоположных решений при применении одного и того же закона, в связи с чем автор (Г.И. Цепляева) предлагает дополнить ч. 2 ст. 10 УК РФ новеллой следующего содержания: «При пересмотре приговора на основании нового, более мягкого, уголовного закона пределами сокращения наказания являются максимальные размеры санкции нового закона без учета положений главы 10 Уголовного кодекса РФ и уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации»[21].

Но подобное применение обратной силы уголовного закона грубо нарушает принцип справедливости (ст. 6 УК), так как меры наказания лицам, совершившим различные по степени опасности преступления и, соответственно, осужденным к различным наказаниям, снижались до одинаковых пределов. Автор неоднократно в печати предлагал предусмотреть в законе положение, согласно которому мера наказания каждому осужденному снижалась бы пропорционально смягчению максимального наказания, предусмотренного новым законом в сравнении с максимальным пределом наказания, предусмотренного прежним законом[22]. Это предложение было поддержано и другими авторами[23]. Но практика пошла по другому пути. Как пишет М.Л. Редин в статье «Тупик российского правосудия», нечеткая редакция закона толкуется судами как их право либо вообще не снижать наказание лицу, отбывающему наказание, либо не применять при этом принцип пропорциональности. «Одним словом, судьи применяют его по принципу “как бог на душу положит”»[24].

Конституционный Суд Российской Федерации 20 апреля 2006 г. рассмотрел жалобы А.К. Айжанова, Ю.Н. Александрова и др. (всего 32 человека), осужденных к различным мерам наказания, которым после принятия ФЗ от 08.12. 2003 г. «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации» меры наказания в соответствии с ч. 2 ст. 10 УК РФ и ч. 2 ст. 3 «Закона о введении в действие Уголовного кодекса Российской Федерации» (в ред. Федерального за-

---

[20] См.: *Цепляева Г.И.* Аналогия Общей части УК РФ, или как определить пределы сокращения наказания на основании ч. 2 ст. 10 УК РФ // Российский судья. 2005. № 4: Доступ из СПС КонсультантПлюс.

[21] Там же.

[22] См.: *Якубов А.* Наказуемость деяния и обратная сила уголовного закона // Законность. 1997. № 4. С. 14; *Его же.* Обратная сила уголовного закона: некоторые проблемы совершенствования Уголовного кодекса Российской Федерации. СПб., 2003. С. 113; и др.

[23] См., напр.: *Кауфман М.* Пробелы уголовного законодательства // Законность. 2004. № 2; и др.

[24] *Редин М.Л.* Тупик Российского правосудия // Юрист. 2006. № 5: Доступ из СПС КонсультантПлюс.

кона от 27 декабря 1996 г. № 161-ФЗ) были снижены до максимальных пределов, предусмотренных ФЗ от 08.12.2003 г.

Конституционный суд пришел к выводу: содержащееся в ч. 2 ст. 10 УК предписание о смягчении назначенного по приговору суда наказания в пределах, предусмотренных новым уголовным законом, предполагает применение общих начал назначения наказания, в силу которых в такого рода случаях смягчение наказания будет осуществляться в пределах, определяемых всей совокупностью норм Уголовного кодекса Российской Федерации — не только Особенной его части, но и Общей (п. 3.1 постановления КС).

Как указано в п. 4 постановления Конституционного суда, реализация закрепленного в ч. 2 ст. 54 Конституции РФ и ст. 10 УК РФ принципа, в силу которого уголовный закон, устраняющий или смягчающий ответственность, имеет обратную силу, может быть обеспечена лишь при условии создания надлежащего процессуального механизма[25].

Смягчение наказания в пределах, определяемых всей совокупностью норм УК РФ, как Особенной, так и Общей его частями, по существу, ничем не отличается от рассмотрения дела в надзорном порядке[26]. Симптоматично, что Конституционный суд в п. 4.1. постановления от 20 апреля 2006 г. указал: «Вступивший в законную силу приговор может быть приведен в соответствие с новым уголовным законом и путем его пересмотра в надзорном порядке, который, согласно Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации, осуществляется соответствующим судом надзорной инстанции (статья 403) по надзорному представлению прокурора или надзорной жалобе осужденного, его защитника или законного представителя (статьи 402 и 404) в судебном заседании с участием сторон (статья 407) и может выражаться в отмене или изменении постановленных по уголовному делу приговора и последующих судебных решений (статьи 408 и 410)».

Белорусский законодатель эту сложную проблему практически уже решил. Согласно ч. 2 ст. 9 УК РБ, «если новый уголовный закон смягчает наказуемость деяния, за которое лицо отбывает наказание, суд назначает наказание в соответствии с санкцией нового уголовного закона, руководствуясь ст. 62 настоящего кодекса»[27], содержащей, подобно ст. 60 УК РФ, общие начала назначения наказания.

---

[25] До настоящего времени никаких предложений о создании «надлежащего процессуального механизма» не поступало.

[26] К.В. Бубон также считает, что «применение ст. 10 УК РФ по своей правовой природе весьма близко к функциям судебного надзора» (см.: *Бубон К.В.* Об обратной силе закона и юридических условностях // Адвокат. 2005. № 10).

[27] Комментарий к Уголовному кодексу Республики Беларусь. Минск, 2003. С. 31. Согласно ч. 2 ст. 62 УК РБ, «при назначении наказания суд исходит из принципа индивидуализации наказания, то есть учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, мотивы и цели содеянного, личность виновного, характер нанесенного вреда и размер причиненного ущерба, обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность...».

Принятый через год (18 июля 2000 г.) Закон РБ «О введении в действие УК РБ» указал в ч. 1 ст. 5, что «приговоры, по которым лица, осужденные по УК РБ 1960 г., не отбыли наказание, подлежат пересмотру в тех случаях, когда назначенное судом наказание является более строгим, чем установлено верхним пределом санкции соответствующей статьи УК РБ». Пересмотр приговоров в случаях, указанных в ч. 1 и 2 настоящей статьи, осуществляется в соответствии с ч. 2 ст. 9 Уголовного кодекса Республики Беларусь в порядке, предусмотренном ст. 17 настоящего Закона (ч. 3 ст. 5)[28].

Согласно ч. 2 ст. 17 указанного Закона, «пересмотр приговоров в отношении лиц, указанных в статьях 5 и 10 настоящего Закона, а также в иных случаях, связанных с изменением квалификации преступления, освобождением от наказания за одно из преступлений при осуждении по совокупности преступлений или совокупности приговоров либо назначением наказания по совокупности преступлений или совокупности приговоров, осуществляется в порядке надзора»[29].

Таким образом, пересмотр приговоров осуществляется в порядке надзора как в отношении лиц, отбывающих наказание за одно преступление (ч. 1 ст. 5), так и в тех случаях, когда это преступление входит в совокупность преступлений или в совокупность приговоров (ч. 2 ст. 17 Закона РБ от 18 июля 2000 г.). Данный порядок является идеальным решением проблемы и мог бы быть принят российским законодателем. Однако подобное решение связано с увеличением нагрузки судов субъектов федерации и Верховного суда РФ, тогда как тенденция в части изменения подсудности у нас прямо противоположная[30].

Возможно, для начала приемлемо следующее решение (когда-то надо выполнять постановление Конституционного суда о создании процессуального механизма):

а) Районные судьи применяют обратную силу закона по делам любого уровня, в том числе и по делам, по которым окончательное решение приняли суды субъектов федерации и Верховный суд РФ. Это нельзя признать нормальным. Было бы оправданным рассмотрение подобных дел судами, принявшими окончательное решение по делу, наделив эти суды ограниченными правами судов надзорных инстанций: 1) применять к вступившим в законную силу решениям обратную

---

[28] Комментарий к Уголовному кодексу Республики Беларусь. С. 1142.

[29] Там же. С. 1144. В соответствии со ст. 10 приговоры в отношении военнослужащих срочной службы, осужденных до 1 января 2001 г. к лишению свободы с направлением в дисциплинарный батальон (ст. 33 Уголовного кодекса Республики Беларусь 1960 г.), подлежат пересмотру в тех случаях, когда назначенное судом наказание является более строгим, чем установлено верхним пределом наказания в виде лишения свободы, предусмотренного ч. 1 ст. 56 Уголовного кодекса Республики Беларусь (направление в дисциплинарную воинскую часть).

[30] См., напр., ФЗ от 23 июля 2013 г. «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации...».

силу закона, устраняющего преступность деяния, смягчающего наказание или иным образом улучшающего положение осужденного; 2) отказывать в применении обратной силы закона[31].

б) Предлагаемый порядок целесообразного использования пропорционального снижения наказания является наиболее простым, рациональным и справедливым способом применения обратной силы закона как в тех случаях, когда изменение закона сводится исключительно к смягчению наказания, в том числе и в случае переквалификации действий осужденного, так и для определения максимально возможного наказания в тех случаях, когда дальнейшая индивидуализация наказания осуществляется с применением других, предусмотренных новым законом положений, смягчающих наказание.

Это и было бы переходным (временным) «процессуальным механизмом» применения обратной силы уголовного закона. Со временем, когда у нас появится финансовая возможность, российский законодатель, очевидно, воспользуется опытом белорусского законодателя.

Список литературы

1. *Брайнин Я.М.* Уголовный закон и его применение. М., 1967.

2. *Блум М.И., Тилле А.А.* Обратная сила закона. Действие советского уголовного закона во времени. М., 1969.

3. *Бубон К.В.* Об обратной силе закона и юридических условностях // Адвокат. 2005. № 10.

4. *Дурманов Н.Д.* Советский уголовный закон. М., 1967.

5. *Игнатов А.Н.* Введение в изучение уголовного права. Уголовный закон // Уголовное право. Общая часть. Курс лекций. Лекция 1. М., 1996.

6. *Кауфман М.* Пробелы уголовного законодательства // Законность. 2004. № 2.

7. *Коробеев А.* Лоскутное одеяло Уголовного кодекса // Независимая газета. 2013. 13 февр.

8. *Милюков С.Ф.* Российское уголовное законодательство. Опыт критического анализа. СПб., 2000.

9. *Мокринский С.П.* Новый закон и старые гарантии (о действии уголовного закона в пределах времени). Спб., 1909.

10. *Неклюдов Н.А.* Общая часть уголовного права: конспект. Спб., 1875.

11. *Редин М.Л.* Тупик Российского правосудия // Юрист. 2006. № 5: Доступ из СПС КонсультантПлюс.

12. *Сахаров А.Б.* Ответственность за деяния, совершенные до вступления в силу Уголовного кодекса РСФСР // Соц. законность. 1961. № 6.

13. *Таганцев Н.С.* Курс русского уголовного права, читаемый в императорском Спб. университете: Часть Общая. Спб., 1879–1880.

14. *Таганцев Н.С.* Русское уголовное право. Часть Общая. Спб., 1902. Т. 1.

[31] Ст. 408 УПК РФ «Решение суда надзорной инстанции».

15. *Цепляева Г.И.* Аналогия Общей части УК РФ, или как определить пределы сокращения наказания на основании ч. 2 ст. 10 УК РФ // Российский судья. 2005. № 4: Доступ из СПС КонсультантПлюс.

16. *Шаргородский М.Д.* Уголовный закон. М., 1948.

17. *Якубов А.* Наказуемость деяния и обратная сила уголовного закона // Законность. 1997. № 4.

18. *Якубов А.Е.* Обратная сила уголовного закона: некоторые проблемы совершенствования Уголовного кодекса Российской Федерации. СПб., 2003.

19. *Якубов А.Е.* Сроки давности в уголовном праве // Законность. 2010. № 8.